

1500634-27.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Sobre o assunto, o Supremo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500634-27.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500634-27.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086310/2022 - DEL.POL.PLANTÃO

SALTO, 23941930 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 2086310 - DEL.POL.SALTO, 2086310 -

DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu MARCOS HENRIQUE DA SILVA como incurso no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III (nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza), ambos da Lei nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 29 de março de 2022, por volta das 13h35min, na Avenida João Jabur, nº 330, Jardim Saltense, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, trazia consigo e guardava para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 55 (cinquenta e cinco) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 26,30g (vinte e seis gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 10 de maio de 2022 (fls. 44-48 ).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls.56-59).

A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 64-65).

Preliminar de ausência de justa causa foi apreciada e rejeitada pela decisão fls. 64-65.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por negativa de autoria ou falta de provas, alternativamente, requereu a aplicação de pena no mínimo legal.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl.01), boletim de ocorrência (fls.02-04), auto de exibição e apreensão (fl.06), auto de constatação preliminar (fl.07) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 36-39) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

As testemunhas Valdevino da Silva e Fábio Magno Galvão de França, guardas municipais, em resumo, relataram que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim União, quando uma senhora avisou que estavam vendendo droga na praça. Chegando na mencionada praça, avistaram o acusado que, ao ver a viatura, levantou-se, colocou a mão dentro do shorts, pegou uma sacola plástica e colocou dentro da roda de um veículo preto que estava estacionado em local próximo. Aí ele saiu e pegou uma cerveja e retornou ao local que estava. Recuperaram o embrulho que continha bastantes pinos de cocaína.

A testemunha Daniele Cardoso Castro disse que viu o momento da prisão. Estava esperando os sobrinhos na praça. Esperou por quarenta minutos mais ou menos. Viu o acusado já no interior da viatura, não notou a abordagem realizada pelos guardas. Silmara da Silva Valentim afirmou que estava presente no momento da prisão. Foi com a comadre buscar os sobrinhos na praça. Os guardas chegaram pararam ao lado do carro estacionado, acharam a droga, chamaram o Marcos que estava do outro lado da praça, o chamaram e o prenderam. Não viu quem colocou a droga próximo ao carro.

O réu, Marcos Henrique da Silva, interrogado judicialmente, disse, em resumo que estava na Praça do Jardim União, sentado, quando ouviu um grito "tá moiado, a guarda tá descendo". Um dos "moleques" que estava ali, saiu do mato, dispensou um kit de drogas próximo ao seu pé e se afastou. Os guardas o abordaram e lhe deram voz de prisão dizendo que a droga achada era dele.

Com efeito, os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu trazia consigo e guardava para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 55 (cinquenta e cinco) porções de "cocaína" e ao perceber a presença da viatura, tentou esconder o embrulho plástico na roda de um veículo estacionado próximo ao local, sendo, entretanto, o entorpecente localizado pelos guardas municipais.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda

Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021) As testemunhas de defesa nada esclareceram de relevante sobre os fatos, afinal nenhuma delas diss ter presenciado o momento em que a droga foi colocada no veículo que estava na praça, não se podendo, portanto, descartar a versão apresentada pelos guardas civis.

A versão apresentada pelo réu no sentido de que a droga tira sido dispensada por terceira pessoa, próximo ao seu pé, não restou minimamente demonstrada. Além de se mostrar inverossímil, afinal o acusado disse que um "moleque" saiu do mato, dispensou a droga próximo ao seu pé e saiu rumo a local ignorado. Não indicando quem seria o tal moleque e nem porque tal pessoa sairia do mato para esconder a droga na praça à vista de outras pessoas, especialmente dos guardas, tanto que estes localizaram a droga. Finalmente, não se crê que os guardas civis simplesmente mentiriam para prejudicar o acusado. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal(2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado.

Não obstante a negativa de autoria pelo acusado, certo é que os demais depoimentos colhidos em conjunto com as provas materiais produzidas, são suficientes a embasar o decreto condenatório, haja vista que as circunstâncias da prisão, a forma como estavam individualmente embalados e à apreensão de dinheiro, indicam que eram destinados à entrega e consumo de terceiros, evidenciando o intuito mercantil, sendo suficientes a embasar o decreto condenatório.

Salienta-se que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao local onde o crime foi cometido, afinal os entorpecentes foram apreendidos em praça pública, local que além de não constar no rol da lei de regência, tampouco se enquadra como "recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza", porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem. Ainda, não restou demonstrado que o local conta com quaisquer atrativos que ensejem a aglomeração de grande número de pessoas.

Nesse sentido tem-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de drogas. Apelos defensivos e do Ministério Público. Pleito da defesa que busca a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade. Pleito Ministerial que busca o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, III, da Lei de Drogas. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Cabível o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Atos infracionais anteriores não se prestam a revelar o envolvimento em atividades criminosas. Concessão do benefício. Redução em 2/3. Afastamento da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas. Rol taxativo que não contempla "praças públicas". Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fixação do regime aberto com expedição de alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1501162-16.2019.8.26.0575; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 01/04/2020)".

Anoto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, firmou entendimento de que "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual. Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 26,30g (vinte e seis gramas e trinta centigramas) de cocaína, o réu é primário (fls. 17-18) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de policiais militares sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo.

Finalmente, em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. No mesmo sentido, a Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 dar repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que a sentenciada não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento do celular o IPHONE XS PRETO e da importância em dinheiro pertencente ao réu, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a réu é primária, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas negativamente diante da variedade e quantidade de droga apreendida, mas evitando a ocorrência de bis in idem, a quantidade será valorada na terceira fase da dosimetria, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)

dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu MARCOS HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet. Oportunamente, ao arquivo. Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA